

1500634-17.2022.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru-SP - cep 17060-000

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500634-17.2022.8.26.0594

Classe – Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marina Freire

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 7 de junho de 2022, por volta das 16h, no cruzamento das ruas Nelson Tosoni Decarlis e Eduardo Ruiz, Parque Primavera, nesta cidade e Comarca de Bauru, trazia consigo 10,37 g de entorpecente conhecido como cocaína, divididos em 37 porções, bem como tinha em depósito 8,3 g de entorpecente conhecido como crack, divididos em 45 porções, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Oferecida a denúncia (fls. 1/4), por decisão de fls. 92/93 foi determinada a notificação do réu.

O réu foi notificado (fl. 101) e apresentou defesa prévia à fl. 111.

A decisão de fl. 113 recebeu a denúncia e deu início à fase de instrução, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, o réu foi interrogado (fls. 163/164-mídia).

Superada a fase de diligências, em alegações finais o representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas (fls. 167/172).

Em outro ângulo, a Defesa rogou pela absolvição diante da ausência de provas e de elementos para corroborar um édito condenatório. Subsidiariamente, em caso de condenação, sustentou e pleiteou a desclassificação do delito para a figura do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Ainda, pugnou pelo reconhecimento da confissão informal e fixação de regime inicial diverso do fechado (fls. 177/191).

É o relatório.
DECIDO.

Trata-se de ação penal pública instaurada para a apuração do crime de tráfico de drogas.

O conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à procedência da denúncia.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 5/6, boletim de ocorrência de fls. 11/13, auto de exibição e apreensão de fl. 15, laudo de constatação provisória de fls. 29/35, laudo toxicológico definitivo de fls. 73/77, laudo pericial de fls. 78/81, bem como pela prova oral amealhada nos autos.

A imputação da autoria do delito ao réu é igualmente inarredável, pois foi fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática criminosa. Disse que, no momento dos fatos, havia acabado de adquirir 37 porções de cocaína, sendo que o indivíduo que lhe vendeu o entorpecente fugiu ao avistar a aproximação do veículo descaracterizado. Mencionou ter afirmado aos policiais que apenas estava adquirindo a droga, bem como nada de ilícito havia em sua residência, onde somente foi encontrada uma balança. Negou ser proprietário das porções de crack localizadas na vegetação (fls. 163/164-mídia).

O policial civil Wesley Belloni Vieira relatou que, em trabalho de investigação no Parque Roosevelt e nos conhecidos pontos de venda de drogas, observou o réu efetuando gestos de troca com pessoas, sendo que ele retirava algo de sua bolsa pochete e entregava aos indivíduos, assim como ia a uma vegetação e retornava ao encontro das pessoas. Falou que, na data dos fatos, conseguiu se aproximar do réu fazendo uso de viatura descaracterizada, quando então procedeu à abordagem, localizando na bolsa pochete do réu 37 porções de cocaína e cerca de R\$ 600,00. Acrescentou ter encontrado 45 porções de crack na vegetação. Esclareceu que o réu informou seu endereço e autorizou o ingresso no imóvel, onde foi apreendida uma balança. Aduziu que o réu informalmente confessou exercer a atividade ilícita naquele ponto em alguns dias da semana e o dinheiro era oriundo da mercancia. Contou que as observações duraram de 15 a 20 dias e esteve em sete diligências, tendo notado a atuação do réu em quatro oportunidades (fls. 163/164-mídia).

No mesmo sentido, o investigador de polícia André Luís Mustafá narrou que, ao efetuar trabalho de averiguação no local, observou o réu na via pública realizando a venda de entorpecentes, pois ele fazia gestos de trocas com indivíduos, pegando algo em sua bolsa pochete ou na região de mata existente nas proximidades. Explicou

ter feito observações à distância, por meio de binóculos, como também se aproximando do réu, constatando que se tratava de venda de estupefacientes. Reportou que, no dia dos fatos, viu o réu realizando vendas, motivo pelo qual ele foi abordado, tendo sido localizadas porções de cocaína na bolsa pochete e pedras de crack escondidas em uma moita. Asseverou que o réu admitiu a prática criminosa. Esclareceu que não foi possível registrar fotografias ou vídeos durante as investigações de campo, bem como não houve atuação do canil da Polícia Militar no local a fim de procurar por outras porções de drogas (fls. 163/164-mídia).

Ao que se vê, as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais civis que participaram da abordagem e da apreensão dos entorpecentes, dão respaldo ao decreto condenatório.

As circunstâncias evidenciam a prática do delito nas modalidades “trazer consigo” e “ter em depósito”, verbos nucleares trazidos pelo tipo penal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A negativa do réu quanto à traficância em nada muda o cenário probatório produzido nos autos, pois tudo que foi apurado leva à comprovação do delito descrito na denúncia.

Diversamente do propugnado pela Defesa, a reconstrução histórica dos acontecimentos, propiciada pela produção probatória, tornou certo o envolvimento do réu com o tráfico ilícito de entorpecentes.

De fato, restou cabalmente demonstrado que os policiais civis realizaram trabalho de investigação e flagraram a atuação do réu no local, destacando-se a constatação de gestos típicos de compra e venda, sendo que ora o réu retirava objetos de sua pochete, ora se dirigia a um matagal próximo e retornava aos usuários. E, na data dos fatos, depois de novamente presenciarem a comercialização de drogas, os investigadores, com a utilização de veículo descaracterizado, aproximaram-se do réu e efetuaram a abordagem, localizando em sua bolsa pochete 37 eppendorfs de cocaína, além da quantia de R\$ 646,00; no matagal utilizado pelo réu foram encontradas 45 pedras de crack e, em sua residência, foi apreendida uma balança de precisão.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos policiais, os quais apresentaram as mesmas versões em ambas as fases do procedimento, razão pela qual merecedores de credibilidade. A essência dos depoimentos dos investigadores revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não podem ser desconsiderados os depoimentos dos agentes, servidores públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar o réu. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos investigadores, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de

concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes." (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018).

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.

1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no writ, seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (STJ. HC nº 267.025 – DF. Relator: Ministro Jorge Mussi. Data do julgamento: 02 de maio de 2013) (destaquei)

Ora, diante dos depoimentos dos investigadores, de toda prova produzida e com riqueza de detalhes de como se deram os fatos, não há se falar em fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Da análise do boletim de ocorrência de fls. 11/13, do auto de exibição e apreensão de fl. 15, do laudo de constatação provisória de fls. 29/35, do laudo toxicológico definitivo de fls. 73/77 e do laudo pericial de fls. 78/81, nota-se que foram apreendidas 42 porções de cocaína (10,37 g), 45 pedras de crack (8,3 g), R\$ 646,00 e uma balança de precisão com resquícios de cocaína e cafeína, a corroborar o exercício da traficância.

Não fosse pela prova oral produzida, já tão suficiente à condenação, a variedade, a quantidade e a forma como os produtos apreendidos foram encontrados encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da destinação ao comércio.

Igualmente, para a consumação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, crime permanente, basta a prática da conduta do núcleo do tipo, ou seja, uma das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

É certo também que a legislação antidrogas estabelece que, para a caracterização do crime de tráfico, mister a análise da natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente de drogas. A quantidade de droga apreendida tem sido referencial na jurisprudência brasileira para caracterização do ilícito da mercancia. Claro que não basta essa única circunstância. Todo conjunto probatório leva à responsabilização do réu. Nesse sentido:

[...] 5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato do réu não ter sido preso em atos de traficância, por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque

tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STJ [...] (TJSP. 3ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001686-11.2011.8.26.0400. Relator: Des. Airton Vieira. Data do julgamento: 10 de outubro de 2017)

De se notar que, embora o réu negue o tráfico, afirmando ser usuário, é certo que tal negativa não passou de uma tentativa para desclassificar o delito. Aliás, a alegação de ser usuário não alija a traficância. Muitos traficantes buscam como meio de defesa a desclassificação da infração penal. E, neste ponto, deve-se salientar não ser uma situação excludente da outra.

Por todo o exposto, entendo que o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento, pelo réu, do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

A culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu não ostenta antecedentes criminais, a não ser a reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do delito não lhes são desfavoráveis.

Destarte, por inexistir circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (fls. 45/46: Execução da Pena nº 0016832-31.2019.8.26.0071, referente ao processo nº 0001207-08.2017.8.26.0594). Assim, por se tratar de reincidência específica, majoro a pena em 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Por outro lado, não há se falar em atenuante da confissão espontânea, pois realizada de forma parcial e de encontro à totalidade da prova dos autos, uma vez que o réu apenas admitiu a posse de parte dos entorpecentes e para próprio consumo. Aliás, é de fundamental importância enfatizar o teor do enunciado da Súmula nº 630 do STJ:

SÚMULA N. 630. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

Dessa maneira, a sanção fica mantida da forma como anteriormente fixada.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. Também não é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do réu, bem como a nocividade, a variedade e a quantidade de entorpecentes apreendidos, fato que revela a dedicação do réu a atividades delitivas, com a existência de uma estrutura voltada à prática da traficância. Dessa forma, ficam as penas mantidas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

O regime inicial deverá ser o fechado (artigo 33, § 2º, "a" e "b", do Estatuto Repressivo), considerados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal e a reincidência do réu. Ademais, é preciso sempre deixar claro que se trata de delito de tráfico ilícito de entorpecentes, equiparado ao crime hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88) e que a própria Carta Magna previu tratamento diferenciado, mais rigoroso, em razão da nocividade desse delito para o bem-estar social. Além disso, o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, com a redação dada pela Lei nº

11.464/2007, dispõe que será cumprida inicialmente em regime fechado a pena por crime de tráfico de drogas. Ainda, a fixação do regime fechado é imprescindível à prevenção e repressão do crime cometido, de modo a atender o princípio da suficiência da pena (artigo 59 do Estatuto Repressivo).

Por fim, nos termos do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006, é vedada a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, além, é claro, do não atendimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL para CONDENAR o réu MARCOS VINÍCIUS DA SILVA à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional vigente à época da infração para cada dia-multa, por violação ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da Constituição Federal).

Comprovada a origem ilícita do dinheiro apreendido nos autos (fl. 15), decreto o perdimento da importância em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/2006. Transitada em julgado, providencie-se a transferência do numerário para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD (artigo 63, § 4º, da Lei de Tóxicos).

Outrossim, decreto a perda do objeto apreendido (fl. 15: balança de precisão), devendo ser observado o disposto nos artigos 516 e 517 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

O réu respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão e da pena ora aplicada, bem como pela reincidência, além das razões já expostas às fls. 50/54 e 145, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA